

1500943-23.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 - grifei).

Assim, mesmo sem mandado judicial, tratando-se o crime de tráfico de drogas permanente, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500943-23.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172313/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25766392 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2172313 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CONCEIÇÃO SILVEIRA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Aos 04 dias do mês de outubro de 2022 à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora, dra. Adriana Aparecida Ossete da Silva. Apresentados o acusado DIEGO CONCEIÇÃO SILVEIRA e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Luciano Fernandes dos Santos e Gilmar Pereira da Costa.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram

colhidos os depoimentos das testemunhas (Luciano e Gilmar) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, DIEGO CONCEIÇÃO SILVEIRA está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de junho de 2022, por volta de 16h00min, na rua Nicolau T Filho, altura do n. 100, Água Branca, e na rua Sebastião Bego, n. 307, Água Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, DIEGO CONCEIÇÃO SILVEIRA, qualificado e indiciado às fls. 05, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 1.083 (um mil e oitenta e três) porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 1.983g (um mil, novecentos e oitenta e três gramas), 1.112 (um mil, cento e doze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 278g (duzentos e setenta e oito gramas), 168 (cento e sessenta e oito) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 20g (vinte gramas), e 01(uma) porção de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 875g (oitocentos e setenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o denunciado trazendo uma sacola em uma bicicleta e perceberam que ele, ao ver a viatura, imprimiu velocidade e tentou abrigo em uma residência.

Feita a abordagem, os agentes encontraram na citada sacola 100 (cem) porções de maconha, 100 (cem) de cocaína e 168 (cento e sessenta e oito) porções de crack, bem como R\$282,00. Na sequência, com base em informações do próprio denunciado, os policiais foram até a residência deste e apreenderam dentro de uma caixa de som o restante das drogas acima descritas, 3.000 (três mil) eppendorfs vazios, 5 (cinco) rolos de plástico filme e uma pequena balança.

Aos policiais, o denunciado confessou que estava traficando drogas.

Na delegacia, porém, ficou silente (fls. 05). Auto de exibição e apreensão de fls. 17-18, laudo pericial provisório de fls. 13-16.

Considerando as circunstâncias da prisão, a quantidade, diversidade e forma de embalagem dos entorpecentes, é certo que o denunciado os trazia consigo, guardava e tinha em depósito com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA JUDICIAL

GILMAR PEREIRADA COSTA – PM – narrou que estavam de patrulhamento pelo bairro quando viu o réu conduzindo uma bicicleta com uma sacola em uma das mãos. Ao ver a viatura, o réu empreendeu maior velocidade até entrar uma residência. Conseguiu abordá-lo ainda na garagem e na sacola tinham drogas e dinheiro. Ele confessou o tráfico. A residência era da mãe do réu e ele morava nas proximidades. Foram até a residência do réu, cuja entrada foi por ele franqueada, onde encontraram mais drogas e uma balança de precisão. As drogas estavam em um dos quartos, dentro de uma caixa de som. O local onde viu o réu na bicicleta é um ponto de grande incidência de tráfico. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, LUCIANO FERNANDES DOS SANTOS – PM.

Interrogado, o réu disse que recebia R\$800,00 para guardar drogas. Havia um mês que estava guardando os entorpecentes. Que foi abordado na casa de sua mãe. Que não estava na rua com a bicicleta.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: “ A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura

do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

DA PENA

Denunciado que ostenta envolvimento com a prática de atos infracionais com o Juizado da Infância e da Juventude, detido em poder de grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes.

Cumprasse assentar que o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas instituiu o denominado tráfico privilegiado que, a prestigiar o princípio da individualização da pena, tem por objetivo diferenciar as penas impostas ao traficante eventual e daquele que habitualmente se dedica à atividade espúria.

Após longa discussão doutrinária e jurisprudencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº118.533/MS, reconheceu que a figura do "tráfico privilegiado de drogas" não ostenta natureza hedionda. Posicionamento semelhante seguiu o Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar² o enunciado de sua súmula nº 512. Pois bem, à incidência da diminuição em voga demandam alguns requisitos cumulativos, quais sejam, a i) primariedade e ii) bons antecedentes do agente, a iii) não dedicação a atividades criminosas e, por fim, iv) não integração de organização criminosa. Na ausência de um destes elementos inviabiliza-se o reconhecimento da causa de diminuição.

É sabido que elevadas porções de drogas são manejadas por pessoas de "responsabilidade" no crime, não sendo meros novatos ou eventuais participantes. Ou seja, a quantidade elevada, bem como a diversidade da droga apontam certa dedicação a atividades criminosas, inclusive indicando ligação a grupos organizados na distribuição e comércio de drogas, circunstâncias que inviabilizam a aplicação da benesse.

Daí que a quantidade e diversidade de drogas, ainda que o agente seja primário, atuam como fatores impeditivos à incidência da causa de diminuição em apreço³, na medida que denotam dedicação a atividades criminosas, sobretudo nos casos em que o agente sequer ostentar ocupação lícita.

No ponto: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTROVÉRSIA REFERENTE À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO DA PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A1 (HC 118533, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016).2 (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).3

Precedentes: STF: HC 174.547 - SP (2010/0097885-5); HC 170.830/SP; HC 171.633/SP, HC 141.921/SP. NÃO DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. Na espécie, o fato que ensejou a não aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (entrega de droga pela Paciente a usuários a mando do seu marido em razão do receio deste de ser descoberto) é hígido e suficiente para atestar a dedicação à atividade criminosa. 2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de não ser possível aplicar a causa de diminuição prevista no art.33, § 4º, da Lei 11.343/06 à pena-base relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei6.368/76, sob pena de se estar criando nova lei que conteria o mais benéfico de cada qual das leis Precedentes. 4. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos prejudicado em razão da não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Ordem denegada.(HC 103153, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/08/2010, DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 EMENT VOL-02436-01PP-00072).Nesse cenário, porque evidenciada a dedicação a atividades criminosas, resta inviabilizado o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º da Lei 11.343/06.

Não cabe a substituição da pena pela privativa restritiva de direitos.

Regime fechado.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação anexa ao SAJ.

Em seguida pela MM.Juiza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

DIEGO CONCEIÇÃO SILVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de junho de 2022, por volta de 16h00, na Rua Nicolau T. Filho, altura do nº 100, Água Branca, e na rua Sebastião Bego, nº 307, Água Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 1.083 (um mil e oitenta e três) porções de

Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 1.983g (um mil, novecentos e oitenta e três gramas), 1.112 (um mil, cento e doze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 278g (duzentos e setenta e oito gramas), 168 (cento e sessenta e oito) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 20g (vinte gramas), e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 875g (oitocentos e setenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o réu trazendo uma sacola em uma bicicleta e perceberam que ele, ao ver a viatura, imprimiu velocidade e tentou abrigo em uma residência.

Feita a abordagem, os agentes encontraram na citada sacola 100 (cem) porções de maconha, 100 (cem) de cocaína e 168 (cento e sessenta e oito) porções de crack, bem como R\$282,00.

Na sequência, com base em informações do próprio réu, os policiais foram até a residência dele e apreenderam dentro de uma caixa de som o restante das drogas acima descritas, 3.000 (três mil) eppendorfs vazios, 5 (cinco) rolos de plástico filme e uma pequena balança.

Aos policiais, o réu confessou que estava traficando drogas. Na Delegacia, porém, ficou silente (fls. 05).

Considerando as circunstâncias da prisão, a quantidade, diversidade e forma de embalagem dos entorpecentes, é certo que o réu os trazia consigo, guardava e tinha em depósito com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 69/79), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 82/83).

Notificado (fls. 89), o réu apresentou defesa prévia, na qual alegou não haver questões preliminares a serem tratadas, sendo as questões de mérito discutidas posteriormente e requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 93/94).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência e mantendo-se a prisão cautelar (fls. 109/111). O réu foi citado (fls. 138).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

Nem se diga que a prova é nula, na medida em que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial.

Em recurso extraordinário representativo de controvérsia, assim se manifestaram os Ministros da Corte Suprema:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o

direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 - grifei).

Assim, mesmo sem mandado judicial, tratando-se o crime de tráfico de drogas permanente, os policiais militares tinham a possibilidade de ingresso na residência, desde que houvesse justa causa.

E a justa causa encontra abrigo nos autos.

Como se verifica da prova oral, os policiais inicialmente visualizaram o réu pedalando uma bicicleta e, ao perceber a aproximação da viatura, ele imprimiu maior velocidade e tentou se abrigar em residência que não lhe pertencia, sendo abordado na garagem da residência, cujo portão basculante estava aberto.

Note-se que a afirmação do réu não pode ser reconhecida, até porque não arrolou testemunhas para confirmar que estava dentro da casa e os policiais a teriam invadido.

Então, não estando na sua própria residência, não havia a proteção constitucional à moradia e, portanto, a abordagem foi lícita.

De outra banda, na sacola que o réu carregava, os policiais já encontraram expressiva quantidade de drogas, ou seja, deste esse momento já havia flagrante.

Por fim, o réu indicou aos policiais que havia mais droga na sua residência, ou seja, quando ingressaram na moradia do réu, os policiais já tinham certeza de que lá havia mais drogas e, de fato, outra grande quantidade de entorpecentes foram ali apreendidos.

Nesse sentido, no momento em que os policiais ingressaram na residência, tinham a confissão do réu de que guardava drogas e, portanto, havia justa causa à ação policial.

Nesse sentido:

"Em que pese a inviolabilidade domiciliar, o estado flagrancial, como predisposto pela Constituição Federal, é medida excepcional. Perfilhando o Auto de Prisão em Flagrante, percebo que o ingresso domiciliar deu-se em função de o réu ter asseverado, quando abordado por atitude suspeita nas ruas, possuir mais entorpecentes em seu domicílio, ensejando o deslocamento das autoridades policiais à casa. Sob tais circunstâncias, o flagrante delito torna-se perfeitamente válido, porquanto subsistia a prática da infração, na medida em que os entorpecentes foram encontrados dentro da localidade em que o acusado apontou como seu domicílio, ali alocados em uma caixa de perfumes, a conduta incorrendo no verbo "guardar", nas conformidades do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Por consequência, não há ferimento ao princípio da inviolabilidade domiciliar, superado pelo estado flagrancial. Os Policiais Militares estavam munidos de indícios suficientes que delatassem a prática do crime intra muros, o próprio réu confessando a manutenção da droga. (STJ - HC: 732676 GO 2022/0092070-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 01/07/2022)".

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 162709 - SP (2022/0087828-9) DECISÃO Conforme relatado, busca-se com o presente recurso a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Inicialmente, destaco que o pedido de declaração de nulidade da busca domiciliar não comporta conhecimento. Isso porque foram formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo recorrente no HC n. 692.133/SP de minha relatoria, o qual foi julgado na sessão do dia 8/3/2022, pela e. Quinta Turma desta Corte Superior, que desproveu o agravo regimental interposto no writ em questão. O acórdão restou assim ementado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE

DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGRAVADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE. REINCENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No caso em análise, consta dos autos que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel que, mediante o auxílio de um cão farejador, encontraram as porções de droga na área dos fundos da casa, no telhado, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. Assim, não há falar em nulidade do flagrante decorrente da violação de domicílio. (STJ - RHC: 162709 SP 2022/0087828-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2022 - grifei).

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no laudo de constatação de fls. 13/16, no auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, nas fotografias de fls. 21/27, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 105/108, segundo o qual foram detectadas Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05).

Em Juízo, o réu afirmou que no dia 26/06, por volta de 13h40, estava dentro da casa da mãe, mas escutaram um barulho e foram verificar. Os policiais abriram o portão basculante da casa com a mão, apontaram a arma na sua direção e mandaram que deitasse no chão. Foi colocado na viatura e levado para sua casa. Lá, os policiais encontraram toda a droga. Ganhou R\$ 800,00 por mês, para guardar a droga. O dinheiro apreendido estava na casa dele e era proveniente do trabalho com seu padrasto. Havia outras pessoas na casa, além dele, como sua mãe, o padrasto e os dois irmãos. Não tinha drogas em seu poder, na casa da mãe. Não havia nenhuma bicicleta, estava dentro da casa da mãe. Estava usando drogas e teve recaída.

A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial militar Luciano Fernandes dos Santos narrou que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu de bicicleta, com uma sacola na mão. Quando avistou a bicicleta, ele imprimiu maior velocidade e ingressou num portão basculante aberto, que era a casa da mãe dele. Ele foi abordado debaixo do portão. Na sacola, havia drogas e dinheiro. O réu disse que passava por dificuldades financeiras e repassava para os "moleques" revenderem, para melhorar a situação financeira. O réu também disse que não morava ali e que na sua casa, havia mais drogas. No endereço que ele indicou, encontraram mais drogas, balança de precisão e material de embalagem. O réu autorizou o ingresso dos policiais na casa, tanto que ele mesmo abriu a porta com a chave. Não conhecia o réu. A primeira casa tem piscina, churrasqueira e a casa é recuada. Não sabe se a casa do réu era simples, não ficou olhando. Era uma casa boa.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Gilmar Pereira da Costa, que relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Oriente, em local de bastante incidência de tráfico, quando avistaram o réu conduzindo uma bicicleta. Ele estava pedalando e segurava uma sacola em uma das mãos. Quando avistou a viatura, o réu passou a pedalar mais rápido e assim que virou a esquina, ingressou numa garagem, cujo portão basculante estava aberto. Ele foi abordado naquela garagem, que era da casa de sua mãe, onde ele não morava. Na sacola, estava parte

da droga e dinheiro trocado e ele disse que ele era o responsável pela distribuição da droga aos adolescente, que ficavam na venda a varejo. Indagado, o réu informou onde era sua residência, na qual, segundo ele, havia mais drogas. Nesse endereço, autorizados pelo réu, ingressaram e, no local apontado pelo réu, uma caixa de som automotiva em um dos quartos, encontraram mais grande quantidade de drogas e material de embalo, além de balança. O réu disse que morava com a amásia, mas na abordagem não havia outras pessoas na casa. A mãe do réu acompanhou a diligência na casa do réu. Posteriormente à abordagem do réu, a mãe dele saiu da casa, com outros moradores. No momento da abordagem, o réu estava sozinho. Não conhecia o réu. O réu estava a meio quarteirão de distância da casa da mãe, quando foi avistado. O réu mora no mesmo bairro da casa da mãe. Consideram ali como Jardim Oriente, mas fica na divisa do bairro Água Branca. Não contaram quantos entorpecentes havia com o réu, na sacola, no momento da abordagem. Só contou a quantidade de drogas no DP. A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Na Delegacia, o réu permaneceu silente. Judicialmente, o réu alegou que a droga estava na sua residência e que a guardava para terceiras pessoas, em troca de R\$ 800,00 por mês.

Ao lado da informação do réu, os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de drogas, quando avistaram o réu pedalando uma bicicleta e carregando uma sacola na mão. Ao perceber a presença dos policiais, o réu acelerou a marcha e ingressou numa garagem, que estava com o portão basculante aberto, mas foi abordado nesse local. Essa casa era da genitora do réu. Na sacola que o réu trazia consigo, os policiais encontraram grande quantidade de drogas (100 porções de maconha, 100 porções de cocaína e 168 pedras crack), já individualizadas. Com o réu, havia R\$ 282,00 em espécie. Indagado a respeito das drogas, o réu confessou que seriam destinadas a venda e contou que possuía mais entorpecentes em sua residência. Os policiais se deslocaram até a residência do réu onde, devidamente autorizados por ele, encontraram, dentro de uma caixa de som, mais 1.012 porções de maconha e 983 porções de cocaína, além de material de embalo (3.000 microtubos vazios, 05 rolos de plástico filme e uma pequena balança).

Com efeito, existem duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, no sentido de que a droga não estava em seu poder, mas sim na sua guarda, e a dos policiais militares, no sentido de que parte da droga estava na sacola que o réu carregava e o restante na residência dele.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Inicialmente, os policiais militares aduziram que o réu foi visto pedalando a bicicleta e, assim que avistou a aproximação da viatura, ele tentou fuga, descrevendo que agia de forma ilícita.

De outro lado, há grande quantidade de drogas apreendidas na posse e guarda do réu, que comprovam a versão dos policiais.

Além disso, o réu não trouxe qualquer elemento de prova a fastar a palavra dos policiais, mesmo dizendo eu estava dentro da casa e que sua mãe, padrasto e irmãos estavam no mesmo local e teriam presenciado a suposta invasão ao endereço.

Assim, devemos dar crédito ao depoimento uníssono e seguro dos policiais militares que, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos agentes públicos tem validade como prova, em especial quando calcada em outros elementos de prova, como a apreensão de grande quantidade de entorpecente.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE

PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Ressalto que os policiais não conheciam o réu e, se quisessem prejudicá-lo, não precisaria utilizar-se de quantidade expressiva de drogas.

Comprovado o envolvimento do réu com a droga, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprova a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu confirmou que guardava a droga para terceira pessoa. A prova dos autos comprova que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, os policiais estavam em patrulhamento rotineiro, quando avistaram o réu em uma bicicleta e ele, ao notar a aproximação policial, imprimiu velocidade e tentou se abrigar em uma residência. Nesse sentido, a tentativa de fuga indica que o réu tentava se furtar da abordagem, em razão de ilicitude.

A quantidade, variedade e forma de embalagem da droga apreendida (1083 porções de cocaína, 1112 porções de maconha e 168 pedras de crack) indicam que não seria utilizada para consumo próprio, porque usuários não ficam em via pública com tanta droga.

Além da droga, os policiais apreenderam na residência do réu material utilizado para o fracionamento e embalagem da droga (3.000 microtubos vazios, 05 rolos de plástico filme e 01 balança), revelando que a destinação não era o consumo próprio. Além disso, com o réu, havia dinheiro em notas trocadas (fotografia de fls. 25), cuja procedência lícita não foi comprovada, embora o réu tenha mencionado que o recebeu do padrasto, como forma de pagamento pelo seu trabalho.

Nesse contexto, a circunstância da abordagem, a quantidade da droga, sua forma de embalagem e diversidade, os materiais de fracionamento e embalagem, o dinheiro apreendido, a confissão judicial; tudo revela que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

A condenação, assim, é de rigor.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A confissão não é capaz de trazer a pena aquém do mínimo legal.

O artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicado ao caso concreto. Embora o réu seja primário, a significativa quantidade das drogas apreendidas aponta que se trata de traficante de maior envergadura, que não pode ser equiparado aos pequenos traficantes que como regra são presos com ínfimas quantidades de substâncias entorpecentes. Ademais, considerando sua situação empregatícia (desempregado - fls. 11) e qualificação profissional (1º grau completo) indicam que o entorpecente não pertenceria ao réu, que o estaria transportando e guardando para terceira pessoa. A quantidade de droga também revela que a atuação era dividida, ficando o réu responsável pelo armazenamento e transporte da droga, afastando a responsabilidade do real proprietário do entorpecente. Nesse aspecto, entendo que está caracterizado que o réu agia em meio a organização criminosa incompatível com a redução da pena.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos. Ademais, o réu trazia consigo e mantinha em depósito quantidade grande de entorpecentes, que trariam repercussão penal elevada.

Pena final: reclusão de 05 anos, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR DIEGO CONCEIÇÃO SILVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 05 anos, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, diária mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão da quantidade da pena aplicada.

O réu está preso e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença. É que sua condição profissional no momento da prisão (desempregado - fls. 05 ou servente de pedreiro) e seu estado civil (solteiro - fls. 05 ou amasiado) não o prendem ao distrito da culpa. O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser gravíssimo, está intranquilizando a sociedade, porque contribui para a má formação dos jovens desta comunidade e fomenta a prática de outros delitos contra o patrimônio e contra a vida. Assim, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 63) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, servindo-se esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da

ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o réu manifestou desejo de recorrer da sentença, pela MM.Juiza foi dito: "recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defensora intimada do prazo para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):